

2022년도 제59회 변리사 2차 국가자격시험

시험과목	시험시간	수험번호	성명
민사소송법	120분		

※ 제59회 변리사 2차 시험 민사소송법 참고 답안입니다.

본 참고답안에 포함된 내용은 수험생들에게 수험 정보를 제공하기 위하여 만들어진 것이므로 출제교수님이 의도하고 있는 쟁점과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이 점 참고하시어 본 참고답안에 게재된 내용에 기재된 사항을 파악해 주실 것을 요청드리겠습니다.

오랜 시간 동안 고생 많으셨습니다.
좋은 결과를 얻으시기 바라겠습니다.

(주)한빛지적소유권센터

민사소송법 강사 일동 배상

[문제-1] (30점)

의사 甲에 대해 의료사고에 따른 손해배상채권을 가지고 있는 丙은 甲을 상대로 조정 신청을 하면서, 적극적 손해 중 기왕치료비 1억 원을 청구하고, 향후치료비는 유사 判例에 근거하여 개별 항목별로 금액을 산정하여 총 1억 원을 청구하되, 향후 소송 시 신체감정 결과에 따라 확정하여 청구한다는 취지를 밝히고, 또한 위자료로 1억 원을 청구하였는데, 조정이 성립되지 않아 소송으로 이행되었다.

한편 이 무렵, 甲은 친구 乙과 통모하여 乙이 甲을 상대로 甲 소유의 부동산(이 사건 부동산)에 관하여 점유취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 소를 제기하도록 하였고, 甲은 乙의 주장을 모두 인정하는 취지의 답변서를 제출하여 위 답변서 부분이 乙에게 송달되었으며, 甲과 乙은 위 청구 내용과 같은 취지의 화해권고결정을 받아 이를 확정시키고 이에 따라 乙 앞으로 이 사건 부동산에 관한 소유권이전등기(이 사건 등기)가 마쳐졌다. 그러자 丙은 甲과 乙 사이에 이 사건 부동산에 관해 허위의 양도합의가 있었고 이는 사해행위에 해당한다고 주장하면서 乙을 상대로 사해행위 취소 및 원상회복(이 사건 등기의 말소) 청구소송을 제기하였다. (다음 각 물음은 독립적임)

(1) 丙의 乙에 대한 소(訴)가 선행 화해권고결정의 기판력에 반하는지 검토하시오. (10점)

1. 문제의 소재

2. 화해권고결정의 기판력 발생 여부

가. 화해권고결정(법 제231조) - 화해권고결정에 대하여 소정의 기간 내에 이의신청 없으면 재판상 화해와 같은 효력을 가진다(법 제231조, 법 제220조).

나. 화해권고결정의 효력의 성질 - 재판상 화해

判例는 화해권고결정의 효력은 재판상 화해와 같은 효력을 가지며, 재판상 화해는 확정판결과 동일한 효력이 있어 기판력이 발생한다. 다만, 실체법상의 하자가 있는 경우도 마찬가지인가 문제

3. 재판상 화해의 법적 성질(간단하게 언급)

가. 학설 - 소송행위설, 양성설, 사법행위설

나. 判例 - 소송행위설(재판상 화해는 순수한 소송행위로 확정판결과 같은 기판력)이 주류, 조건부 화해를 인정한 것은 양성설의 태도이다.

다. 검토

4. 실체법상의 하자 등이 있는 경우 기판력 인정여부(간단하게 언급)

가. 학설 - 무제한기판력설(소송행위설), 제한적기판력설(양성설), 기판력부정설(사법행위설)

나. 判例 - 과거 양성설의 입장에서 전원합의체 판결로 무제한기판력설 입장으로 변경 (4294민상914, 2011두1917)

다. 검토 - 준재심의 소(법 제461조) 가능하며, 현행법의 취지상 무제한기판력설이 타당

5. 후소가 기판력에 저촉되는지 여부

가. 기판력 의의

나. 기판력의 주관적 범위 - 상대성 원칙(후소 당사자는 채권자와 수익자로 전소 당사자인 채무자와 수익자로서 당사자가 다르다)

다. 기판력의 객관적 범위 및 작용국면

- 기판력은 주문에 발생(법 제216조)

- 전소의 주문에 관하여 후소의 소송물이 동일, 전소가 후소의 선결관계, 모순관계인 경우에 기판력이 작용. 후소의 사해행위취소청구가 전소와 모순관계인지 문제된다.

라. 사해행위취소청구에 대한 기판력의 작용국면

- 判例는 “채권자가 사해행위의 취소와 함께 수익자 또는 전득자로부터 책임재산의 회복을 명하는 사해행위취소의 판결을 받은 경우 수익자 또는 전득자가 채권자에 대하여 사해행위의 취소로 인한 원상회복의무를 부담하게 될 뿐, 채권자와 채무자 사이에서 취소로 인한 법률관계가 형성되는 것은 아니므로, 채무자와 수익자 사이의 소송절차에서 확정판결 등(화해권고결정)을 통해 마쳐진 소유권 이전등기가 사해행위취소로 인한 원상회복으로써 말소된다고 하더라도, 확정판결의 효력에 반하거나 모순되는 것이 아니다”고 판단하였다(대법 2016다204783).

6. 사안의 해결 - 후소는 선행 화해권고결정의 기판력에 반하지 않음

(2) 丙의 乙에 대한 채권자취소소송(전소)에서 丙의 승소 확정판결이 내려졌고 그 뒤 甲에 대해 대여금채권을 가지고 있던 丁이 자신의 채권을 보전하기 위해 乙을 상대로 전소와 같은 취지의 사해행위 취소 및 원상회복 청구소송(후소)을 제기하였다. 乙은 후소의 변론기일에 후소에는 전소의 기판력이 미친다거나 또는 권리보호이익이 없다고 주장한다. 乙의 주장에 대해 법원은 어떤 판단을 하여야 하는지를 설명하시오. (10점)

1. 문제의 소재

2. 기판력의 의의

3. 후소가 전소의 기판력에 저촉되는지 여부

가. 기판력의 주관적 범위

1) 기판력의 상대성 원칙

2) 채권자 취소소송의 경우 - 채권자취소소송의 요건을 갖춘 각 채권자는 채무자의 재산처분행위를 취소하고 그 원상회복을 구할 수 있어, 전소의 기판력이 다른 채권자에게 미

치지 않음

나. 소결 - 기판력이 저촉되지 않음

4. 권리보호이익이 없는지 여부

가. 소의 이익 - 권리보호이익은 소송요건으로 흠결시 부적법 각하

나. 채권자취소소송에서의 소의 이익(判例) (2003다19558)

- 1) 다른 채권자의 승소판결확정시 - 권리보호이익 존재
- 2) 다른 채권자의 원상회복시 - 중첩범위 내에서 권리보호이익 소멸

5. 사안의 해결 - 기판력에 저촉되지 않으나 실제 병의 승소확정판결 후 원상회복이 되었는지 여부에 따라 권리보호이익이 없을 수 있으며 소송요건이 흠결되는 경우 소각하 판결

(3) 丙이 甲을 상대로 제기한 위 손해배상 청구소송(전소)에서 甲이 답변서도 제출하지 않고 변론기일에 불출석하여, 丙의 신체감정 등이 이루어지지 않은 상태에서, ‘피고(甲)는 원고(丙)에게 위 조정신청 내용과 같은 금액 및 이에 대한 지연손해금을 지급하라’는 내용의 자백간주에 의한 전부승소판결이 선고되어 확정되었다. 그 후 丙은 甲에 대해 전소에서 인정된 금액을 제외한 나머지 적극적 손해에 대한 배상금 1억 원과 추가 위자료 1억 원 및 이에 대한 지연손해금을 청구하는 소(후소)를 제기하였다. 이 경우 전소판결의 기판력이 후소에 미치는지 검토하시오. (10점)

1. 문제의 소재

2. 손해배상청구의 소송물

가. 학설 - 손해1개설, 손해2분설, 손해3분설

나. 判例 - 손해3분설(적극적 손해, 소극적 손해, 정신적 손해로 나뉨, 76다1313)

다. 검토 - 손해3분설 타당

3. 일부청구의 소송물

가. 학설 - 일부청구긍정설, 일부청구부정설, 명시설

나. 判例 - 명시설(치료비 청구를 하면서 일부만을 특정하여 청구하고 그 이외의 부분은 별도소송으로 청구하겠다는 취지를 명시적으로 유보한 때 그 소송물은 일부의 치료비에 한정되는 것)

다. 검토 및 기판력의 발생 범위 - 명시설에 따라 기왕 치료비 1억원에 대해서만 발생

4. 기판력에 저촉되는지 여부

가. 기판력의 의의

나. 일부청구의 경우 잔부청구의 기판력 저촉 여부

- 1) 학설 - 일부청구긍정설, 일부청구부정설, 명시설

2) 判例 - (통상적 판례) 명시하여 소제기된 경우 소송물은 채권 일부의 존부뿐이며 전부의 존부는 아니므로 일부청구에 대한 확정판결의 기판력은 나머지 부분의 청구에 미치지 않는다고 하여 명시설(87다카1416)의 입장이다.

(사안에 관한 판례) “선행소송에서 적극적 손해의 개별 항목과 금액을 특정하면서 적극적 손해 중 다른 손해에 대하여는 신체감정에 따라 청구할 것임을 밝힌 점 등을 고려하면, 선행 소송중 적극적 손해에 대한 배상청구부분은 일부청구하는 채권의 범위를 잔부청구와 구별하여 심리의 범위를 특정할 수 있는 정도로 표시하고 전체 채권의 일부로서 우선 청구하고 있는 것임을 밝힌 경우로서 명시적 일부청구에 해당하므로 선행 소송 확정 판결의 기판력이 이 부분 청구에 미치지 않는다”(대법 2013다96165).

3) 검토

기왕치료비와 향후치료비를 구분하여 일부만 청구하였으므로 명시설에 따라 미치지 않음

다. 정신적 손해에 미치는지 여부

1) 判例는 “위자료 청구 부분에 대하여는 선행 소송에서 일부청구임을 명시했다고 볼 수 없으므로 선행 소송 확정판결의 기판력이 위자료 채권 전부에 미친다”고 하였다.

2) 전소의 판결의 기판력은 정신적 손해에 대한 1억 원 청구에 미치며, 승소한 자가 후소에서 별소제기한 위자료 부분에 대하여는 전소의 기판력에 저촉되어 모순금지설의 입장에 따라 소각하 판결을 내려야 한다.

5. 사안의 해결

1) 향후치료비 1억원에 대한 기판력 미치지 않음

2) 위자료 1억원에 대하여 기판력 미침. (선행 소송에서 일부청구임을 명시했다 볼 수 없으므로 판례인 모순금지설의 입장에 따라 소각하 판결을 내려야 한다.)

[문제-2] (20점)

甲이 정당한 이유 없이 X 토지(이 사건 토지)를 甲 소유 건물의 주차장 진출입로로 수년 간 사용하고 있었는데, 이 사건 토지의 소유자라고 주장하는 乙이 이 사건 토지 부분에 펜스(이 사건 펜스)를 설치함으로써 甲의 주차장 출입을 막았다. 그러자 甲은 제1심 법원에 乙이 이 사건 펜스를 설치함으로써 甲의 이 사건 토지에 대한 점유를 침탈하였다는 이유로, 점유물반환청구권에 기해 乙을 상대로 이 사건 펜스의 제거와 이 사건 토지의 인도를 청구하였다. (각 물음은 독립적임)

(1) 乙은 甲의 청구가 인용될 경우에 대비하여 반소(예비적 반소)로써 소유권에 기하여 이 사건 토지의 인도를 청구하였는데, 제1심 법원은 본소와 반소 모두 부적법하다는 이유로 각하하였다. 이에 甲만이 항소하였는데, 항소심 법원은 적법하게 甲의 청구를 인용하면서 乙의 반소에 대해서는 항소하지 않았다는 이유로 판단하지 않았다.

항소심 법원의 판단이 타당한지에 대하여 설명하시오. (10점)

1. 문제의 소재

2. 항소심에서 소각하판결을 취소하고 본소청구를 인용할 수 있는지

가. 필수적 환송제도(법 제418조 본문) - 당사자 심급이익을 보호하기 위함

나. 예외적으로 항소심에서 재판이 가능한 경우(법 제418조 단서)

다. 사안의 경우 - 제1심에서 본안판결을 할 수 있을 정도로 심리가 된 경우라면 환송하지 않고 본소청구의 재판을 할 수 있으나 그렇지 않은 경우 당사자의 심급의 이익을 빼앗은 것으로 위법하다.

3. 항소심에서 예비적 반소의 판단을 누락한 것에 대한 위법성 여부

가. 을의 반소의 성격 - 예비적 반소는 본소 청구가 인용될 것으로 조건으로 심판을 구하는 반소이며, 본소청구가 각하, 취하되면 반소청구도 소멸되며, 본소청구가 기각되면 반소청구에 대하여 아무런 판단이 필요 없다.

나. 갑의 항소시 예비적 반소도 항소심으로 이심되는지 여부 - 전부판결로 상소불가분의 원칙이 적용되어 원고의 본소에 대한 항소로써 피고의 예비적 반소도 확정차단되어 항소심으로 이심된다.

다. 예비적 반소가 심판대상인지 여부

1) 불이익변경금지의 원칙(법 제415조)

2) 학설 - 긍정설(심판대상이다), 부정설(심판대상아니다)

3) 判例 - 제2심은 본소청구를 인용한 이상 예비적 반소청구를 심판대상으로 삼아 판단해야 한다(2006다19061).

4) 검토 - 제1심의 예비적 반소에 대한 판결은 무효이며, 항소, 부대항소의 대상이 아니어서 상급심에서 판단하더라도 불이익변경의 문제가 없어 본소인용시 이를 판단해야 한다.

4. 사안의 해결

본소청구인용한 항소심판단은 문제되지 않으나, 예비적 반소를 판단하지 않은 것은 타당하지 않다(판단누락의 위법)

(2) 제1심 법원이 甲의 청구를 인용하였는데 이에 대하여 乙은 즉각 항소하면서, 甲의 청구가 인용될 경우에 대비하여 반소로써 소유권에 기하여 이 사건 토지의 인도를 청구하였다. 乙의 반소가 적법한지 여부를 검토하시오. (10점)

1. 문제의 소재

2. 반소의 적법 요건

가. 반소의 의의 및 요건(법 제269조) - 상호관련성과 심급의 이익이 문제된다.

나. 본소의 방어방법과 상호관련성이 있는 경우에 대한 쟁점

1) 문제점 - 민법 제208조 2항(점유권에 기한 소는 본권에 관한 이유로 재판하지 못한다)으로 본권을 방어방법으로 행사할 수 없어, 본권에 기한 반소도 금지되는지 문제된다.

2) 학설 - 통설(적법), 소수설(부적법)

3) 判例 - 반소가 적법함을 전제로 점유권에 기한 본소와 본권에 기한 예비적 반소를 모두 인용해야 한다고 하여 통설의 입장

4) 검토 - 본권에 기한 별소가 허용되므로 반소로서 제기하는 것 역시 가능함

다. 심급의 이익을 해할 우려가 있는지 여부

1) 判例 - ① 중간확인의 반소, ② 본소와 청구원인을 같이하는 반소, ③ 제1심에서 충분히 심리한 반소, ④ 항소심에서 예비적 반소를 추가하는 경우

2) 사안의 경우 - 이미 제1심에서 충분히 심리한 경우에 해당하므로 심급의 이익을 해할 우려가 없다.¹⁾

3. 항소의 이익

전부승소 당사자는 원칙적으로 항소의 이익 없으나, 패소 당사자이므로 항소의 이익 인정

4. 기타 소송요건의 구비

위 반소에서 소송요건의 흠결 보이지 않으므로 적법

5. 사안의 해결 - 을의 반소는 적법하다.

[문제-3] (30점)

甲은 마을 모퉁이에 자신의 자동차를 잠시 주차하였는데 그 옆에 기울어져 있던 공작물이 갑자기 쓰러지는 바람에 자신의 자동차가 파손됨은 물론 인신사고로 상해를 입게 되었다. 이에 甲은 공작물의 설치 또는 보존에 하자가 있음을 이유로 하여 공작물의 점유자인 乙을 주위적 피고로, 이것이 인용되지 아니할 경우에 대비하여 공작물의 공유자인 丙, 丁을 예비적 피고로 하여 손해배상을 구하는 소를 제기하였다. (다음 각 물음은 독립적임)

(1) 제1심 법원이 乙에 대한 甲의 청구를 일부 인용하면서 丙, 丁에 대한 청구에 대

1) 참조: 93므1051, 1068판결(이혼사건)에서는 항소심에서 제기한 예비적 반소에 대해 원고가 반소 제기에 대하여 부동의하고 있을 뿐 아니라 본소와 반소의 각 청구원인이 상이한 만큼 원고의 심급의 이익을 해할 우려가 없다고 할 수 없어 부적법하다는 판시를 내린 판례가 있음. 문제에서는 구체적인 사안이 언급되지 않고 있으므로 부적법하다는 부분으로 답안 구성한 경우라도 가능할 여지 있음.

해서는 판결을 하지 않은 경우, 이러한 법원의 판결이 허용되는지 여부에 대하여 설명하시오. (8점)

1. 문제의 소재

2. 이 사건 소송의 병합소송의 법적성질

1) 주관적 예비적 병합이란 여러 사람의 또는 여러 사람에 대한 청구가 논리상 양립할 수 없는 관계가 있는 경우 순위를 붙여 공동원고 또는 공동피고로서 하는 소송형태를 말한다(법 제70조).

2) 법률상 양립불가능의 의미 - “동일한 사실관계에 대한 법률적 평가를 달리하여 두 청구 중 어느 한쪽에 대한 법률효과가 인정되면 다른 쪽에 대한 법률효과가 부정됨으로써 두 청구가 모두 인용될 수 없는 관계가 되는 경우로 실체법적 또는 소송법상으로 서로 양립될 수 없는 경우를 포함한다(2005다49430)

3) 사안의 경우 - 민법 제758조의 규정상 공작물의 설치 또는 보존의 하자로 타인에 손해를 가한 때 1차적으로 공작물 점유자가 손해배상책임을 지나 주의의무를 다한 때 무과실로 소유자가 손해배상책임을 지는 것으로, 점유자의 주의의무 해태의 존부에 따른 손해배상책임 의무가 양립불가능한 경우에 해당하므로 주관적 예비적 병합에 해당한다.

3. 주관적 예비적 공동소송의 심판방법

1) 소송자료의 통일(법 제79조 1항) - 67조 준용, 1인의 유리한 행위는 전원에게, 불리한 행위는 전원이 함께 하여야 한다. 상대방의 소송행위는 유불리 불문 공동소송인 모두에 미친다.

2) 소송진행의 통일(법 제79조 1항) - 67조 3항 준용, 변론의 분리 불허, 공동소송인 일인에 대한 중단 등 사유는 모두에게 미쳐 소송절차 중단된다. 상소기간은 개별적으로 진행되나 모두에 대하여 상소기간이 만료되지 않으면 판결확정되지 않는다.

3) 본안재판의 통일(법 제79조 2항) - 일부판결 불허, 모순없이 합일확정인 판결이어야 한다.

4. 본안재판의 통일과 관련하여 일부판결이 허용되는지 여부

1) 判例의 태도

判例는 “주관적, 예비적 공동소송은 동일한 법률관계에 관하여 모든 공동소송인이 서로 간의 다툼을 하나의 소송절차로 한꺼번에 모순 없이 해결하는 소송형태로서 모든 공동소송인에 대한 청구에 관하여 판결을 하여야 하고, 그중 일부 공동소송인에 대해서만 판결을 하거나 남겨진 당사자를 위하여 추가판결을 하는 것은 허용되지 않는다”고 하여 일부판결을 불허한다.

2) 불복방법 - 判例는 “일부 공동소송인에 관한 청구에 대해서만 판결을 한 경우 일부판결이 아닌 흠이 있는 전부판결에 해당하여 상소로써 이를 다투어야 하고, 판결에서 누락된 공동소송인은 판단누락을 시정하기 위하여 상소를 제기할 이익이 있다”고 하여 일부판결을 판단누락의 위법으로 본다(2005다49430).

3) 사안의 경우 - 병, 정에 대한 판결을 하지 않은 것은 허용되지 않으며 판단누락의 위법이 있다.

5. 사안의 해결

(2) 乙에 대한 甲의 청구를 일부 인용하는 제1심 법원의 판결에 대하여 乙이 항소한 경우 甲이 항소심에서 乙에 대한 소를 취하하는 것이 가능한지 검토하고, 만약 乙에 대한 소가 적법하게 취하되었다면 소를 취하지 않은 丙, 丁에 관한 청구 부분이 여전히 항소심 법원의 심판대상이 되는지에 대해 설명하시오. (14점)

1. 문제의 소재

2. 주관적 예비적 공동소송의 심판방법

1) 소송자료의 통일(법 제79조 1항) - 67조 준용, 1인의 유리한 행위는 전원에게, 불리한 행위는 전원이 함께 하여야 한다. 상대방의 소송행위는 유불리 불문 공동소송인 모두에 미친다.

2) 소송진행의 통일(법 제79조 1항) - 67조 3항 준용, 변론의 분리 불허, 공동소송인 일인에 대한 중단 등 사유는 모두에게 미쳐 소송절차 중단된다. 상소기간은 개별적으로 진행되나 모두에 대하여 상소기간이 만료되지 않으면 판결확정되지 않는다.

3) 본안재판의 통일(법 제79조 2항) - 일부판결 불허, 모순없이 합일확정인 판결이어야 한다.

3. 소송진행의 통일과 관련하여 예비적 공동소송에서 일부 공동소송인에 대한 소취하가 가능한지 여부

가. 원고가 일부 공동소송인에 대한 소취하 또는 청구의 포기

1) 명문의 규정(법 제70조 1항 단서)

법 제70조 1항 단서에서 예비적, 선택적 공동소송에 관하여 청구의 포기, 인낙, 소의 취하의 경우 필수적 공동소송 규정인 제67조 내지 제69조의 규정을 준용하지 아니한다고 하여 소의 취하는 필수적 공동소송의 심판방법에 따른 절차가 적용되지 않는다.

2) 대법원 判例의 태도

判例는 “법은 주관적, 예비적 공동소송에 대하여 필수적 공동소송에 관한 규정인 제67조 내지 제69조를 준용하도록 하면서도 소의 취하의 경우 예외를 인정하여 공동소송인 중 일부가 소를 취하하거나 일부 공동소송인에 대한 소를 취하할 수 있다.”고 하여 공동소송인 일부에 대한 소 취하를 긍정한다(2015다242429 판결).

3) 검토

각 공동소송인이 자신의 소송물을 처분하는 것을 제한하는 것은 가혹하여 예비적, 선택적 공동소송인의 일부가 자유롭게 자주적 해결방식으로 해결하도록 일부 취하를 허용하는 것이 타당하다.

나. 사안의 경우 - 갑이 을에 대해서만 소를 취하하는 것 가능

4. 소를 취하지 않은 나머지 공동소송인에 대한 청구부분이 심판대상이 되는지 여부

1) 判例의 태도

위의 判例에서 “공동소송인 중 일부가 소를 취하거나 일부 공동소송인에 대한 소를 취할 수 있고 이 경우 소를 취하지 않은 나머지 공동소송인에 관한 청구 부분은 여전히 법원의 심판대상이 된다”고 판시한다(위 2015다242429).

2) 사안의 경우 - 갑의 주위적 피고 을에 대한 소 취하에 불구하고 예비적 피고들인 병과 정에 대한 청구에 대하여는 항소심 법원의 심판대상이 된다.

5. 사안의 해결 - 을에 대한 소 취하 가능, 병과 정에 관한 청구부분은 항소심 법원의 심판대상이 된다.(을에 대한 소 취하로 인하여 병과 정에 관한 예비적 병합 관계는 해소됨)

(3) 제1심 법원이 주위적 청구에 대해서는 기각, 예비적 청구에 대해서는 인용하는 판결을 하였고, 이에 丙만이 항소한 경우 그 효력이 타 공동소송인에게도 미치는지 여부에 대하여 설명하시오. (8점)

1. 문제의 소재

2. 주관적, 예비적 공동소송에서의 상소의 통일

1) 상소기간

- 각 공동소송인에게 판결정본 송달이 있을 때부터 개별진행
- 합일확정의 필요에 따라 전원에 대해 상소기간 만료될때까지 확정되지 않음

2) 상소불가분원칙의 적용 및 불이익변경금지원칙의 배제

- 합일확정의 필요에 따라 공동소송인 중 어느 한 사람이 상소를 제기하면 다른 공동소송인에 관한 청구 부분도 확정이 차단되어 상소심에 이심된다.
- 법률상 양립할 수 없는 공동소송인 사이의 분쟁관계를 모순 없이 통일적으로 해결하여 재판의 통일을 기하는 예비적 공동소송제도의 취지상 불이익변경금지 원칙이 적용되지 않는다.

3. 예비적 공동소송인 중 한 사람만이 항소를 제기하였을 때 확정 차단 및 이심의 효력

가. 判例의 태도

判例는 “공탁이 무효임을 전제로 한 피고 갑에 대한 주위적 청구와 공탁이 유효임을 전제로 한 피고 을 및 제1심 공동피고들에 대한 예비적 청구가 공탁의 효력 유무에 따라 두 청구가 모두 인용될 수 없는 관계에 있거나 한쪽 청구에 대한 판단 이유가 다른 쪽 청구에 대한 판단 이유에 영향을 주어 각 청구에 대한 판단 과정이 필연적으로 상호 결합되어 있는 주관적·예비적 공동소송의 관계에서 모든 당사자들 사이에 결론의 합일확정을 기할 필요가 인정되므로, 피고 乙만이 제1심판결에 대하여 적법한 항소를 제기하였다고 하더라도 피고 甲에 대한 주위적 청구 부분과 제1심 공동피고들에 대한 예비적 청구 부분도 함께

확정이 차단되고 원심에 이심되어 심판대상이 되었다고 보아야 한다”고 하여 불복하지 않은 자에 대한 청구들도 모두 항소심의 심판대상이라고 한다(2009다43355).

나. 사안의 경우

이 사건 공작물 하자에 따른 손해배상청구에서 예비적 피고인 병, 정 중 병만이 항소를 제기하더라도 주관적, 예비적 공동소송의 관계에서 합일확정의 필요에 따라 을에 대한 주위적 청구와 정에 대한 예비적 청구 부분은 모두 확정차단되며, 항소심에 이심되어 심판대상이 된다.

4. 상소하지 않고 상소심 심판을 받는자의 지위 - 다른 필수적 공동소송처럼 “상소심당사자”로 본다(통설, 判例).

5. 사안의 해결

[문제-4] (20점)

甲은 수년 전부터 노인성 치매를 이유로 A노인요양센터(법인이 아님)에서 기거해오고 있다. 그런데 A노인요양센터의 열악한 환경으로 인하여 甲은 뜻하지 않은 폐질환에 걸려 투병 중이다. 이에 甲은 현저한 질병 악화 등을 이유로 하여 손해배상을 구하는 소를 제기하려고 한다. (다음 각 물음은 독립적임)

(1) 甲이 소를 제기함에 있어 A노인요양센터가 소송의 상대방이 될 수 있는 능력이 있는지 여부를 검토하시오. (10점)

1. 문제의 소재

2. 당사자능력의 의의 및 유무의 판단 기준

가. 의의 - 소송의 주체가 될 수 있는 일반적인 능력

나. 당사자능력 유무의 판단기준 - 법 제51조(일차적으로 민사소송법, 이차적으로 민법 그 밖의 법률의 권리능력을 기준으로 판단)

다. 권리능력자 - 자연인(민법), 법인(민법, 특별법), 비법인사단 · 비법인재단(법 제52조)

3. 노인요양센터가 비법인재단으로 당사자능력이 인정되는지 여부

가. 비법인재단의 당사자능력 인정 요건

법인 아닌 재단은 ① 재단으로서의 실질(일정한 목적에 따라 일정한 재산, 출연자로부터 독립하여 운영)이 있고, ② 대표자나 관리인이 있으면 당사자능력이 인정된다.

나. 노인요양원이나 노인요양센터에 당사자능력 유무에 대한 判例의 입장(2018다 227865)

“노인요양원이나 노인요양센터는 일반적으로 노인성질환 등으로 도움을 필요로 하는 오 니을 위하여 급식, 요양과 그 밖에 일상생활에 필요한 편의를 제공함을 목적으로 하는 시 설, 즉 노인의료복지시설을 가리키고, 이는 노인요양시설의 명칭 불과하여 당사자 능력이 인정되지 않는다”고 판시하여 당사자능력을 부정

4. 당사자능력 흠결시 소송상 취급

가. 소송요건 - 직권조사사항(사실심 변론종결시 기준)

나. 흠결시 취급 - 당사자표시정정이 허용되면 법 제59조를 유추적용하여 당사자표시정 정을 할 수 있으나, 그렇지 않다면 소송요건의 흠결로 소를 각하한다.

5. 사안의 해결 - 당사자능력 없음

(2) 甲이 A노인요양센터를 피고로 하여²⁾ 손해배상을 구하는 소를 제기하였는데 소송 계속 중 甲이 사망하였다. 甲에게 유일한 상속인으로 乙이 있는 경우 소송당사자의 지위가 수계절차 없이도 乙에게 승계되는지 여부와 법원이 甲의 사망사실을 간과하고 판결하였을 경우 이 판결의 효력에 대하여 검토하시오. (10점)

1. 문제의 소재

2. 소송계속중 당사자 사망시 절차의 중단 여부(간단히 언급)

가. 소송 중 사망과 절차중단 - 소송대리인 없으면 절차중단(제233조), 소송대리인 있으면 절차중단되지 않는다(제238조)

나. 사안의 경우 - 소송대리인 유무에 따라 절차 중단 여부 달라짐

3. 피고 갑의 지위가 상속인 을에게 당연승계되는지 여부

가. 문제점

나. 학설 - 당연승계긍정설(수계절차는 확인적 의미만 있음), 당연승계부정설(수계절차를 밟아 당사자로 표시되어야만 당사자 변경)

다. 判例 - 당연승계긍정설(소송중 당사자가 사망한 때부터 소송은 그 지위를 이어받는 상속인과의 관계에서 대립당사자구조를 형성하게 된다)

라. 검토 - 긍정설 타당

4. 소송계속 중 사망자 간과한 판결의 효력

가. 학설 - 위법설, 무효설

나. 判例 - 위법설(소송에 관여할 수 있는 적법한 수계인의 권한을 배제한 결과가 되는 절차상 위법은 있지만 그 판결이 당연무효라 할 수는 없고, 그 판결은 대리인에 의하여 적 법하게 대리되지 않았던 경우와 마찬가지로 대리권 흠결을 이유로 상소 또는 재심에 의하 여 그 취소를 구할 수 있다)

2) 문제에서는 사망사실을 간과하는 것으로 한정하였으나, 당사자능력이 없는 피고 당사자를 간과한 판 결 효과도 간단히 언급할 수 있어 보입니다.

다. 검토 - 위법설 타당

5. 상속인 을의 구제수단 - 확정전 상소(제424조 1항 4호), 확정후 재심(제451조 1항 3호)

6. 사안의 해결 - 수계절차 없이 당사자 지위 승계되며, 간과판결은 위법하나 유효함